

Storia del diritto medievale e moderno

Lezione 12

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it

La consuetudine nel Medioevo

Quae sit longa consuetudo

C. 8.52.2 (titulus: *quae sit longa consuetudo*)

*Imperator Constantinus . Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem. * CONST. A. AD PROCULUM. * <A 319 D. VIII K. MAI. CONSTANTINO A. V ET LICINIO C. CONSS.>*

L'imperatore Costantino. L'abitudine e l'uso di lunga durata (*consuetudo et usus longaevus*) hanno un'autorità non trascurabile, ma non tale da vincere la ragione o la legge. Costantino Augusto a Proculo. Dato l'8º giorno prima delle Calende di maggio (24 aprile) nell'anno del consolato di Costantino Augusto per la quinta volta e di Licinio Cesare.

La consuetudine nel Medioevo

Quae sit longa consuetudo

Per un andamento tipico della storiografia giuridica, la consuetudine è stata vista per lungo tempo come la fonte giuridica medievale “per eccellenza”. Se la storia del diritto può leggersi anche come storia di una dialettica tra *consuetudo* e *lex*, i secoli medievali pendono dalla parte delle *consuetudines*, cioè quella “quantità più o meno vasta di **norme per così dire allo stato libero**, che vivono maturano si svolgono nella pratica di tutti i giorni spontaneamente, senza alcun intervento di quegli organi, ripetutamente e uniformemente osservate dai soggetti dell’ordinamento” (Francesco Calasso).

La crisi delle strutture pubblicistiche imperiali produce crisi della *lex*, favorendo usi e costumi prodotti dall’esperienza giuridica collettiva.

- *Diritto senza stato* (Paolo Grossi)
- *Diritto senza legge* (Mario Caravale)

La consuetudine nel Medioevo

Quae sit longa consuetudo

L'idea di Calasso è che:

- Come espressione della convinzione popolare, la *consuetudo* costituisce un'area un po' "anarchica" dell'ordinamento (*ius non scriptum*, idea delle "norme allo stato libero")
- Ma persistono nel medioevo atteggiamenti costantiniani nei confronti della *consuetudo*.
- La Chiesa prova a "mettere sotto controllo" la consuetudine. Come tutte le fonti, anche questa deve essere sottoposta al vaglio di compatibilità con la *veritas* di diritto divino. Di qui anche la prassi delle *consuetudines approbatae*.

La consuetudine nel Medioevo

Quae sit longa consuetudo

- Puchta (m. 1846), *Das Gewohnheitsrecht*. Erlangen, 1828-1837 (trad. *Il diritto consuetudinario*)
- Savigny (m. 1861), *System des heutigen römischen Rechts*. 1. Berlin, 1840 (trad. *Sistema di diritto romano attuale*)
- Otto von Gierke (m. 1921), *Deutsches Privatrecht*, I. Leipzig, 1895 (trad. *Diritto privato tedesco*)
- Francesco Calasso (m. 1965), *Storia e sistema delle fonti del diritto comune*. Milano, 1938
- Paolo Grossi (m. 2022), *Un diritto senza Stato...* (Quaderni fiorentini, 1996)
- Mario Caravale, *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*. Torino, 2013.

[Conte, 2009; Id., 2008 \(moodle\)](#)

La consuetudine nel Medioevo

Quae sit longa consuetudo

- Puchta (m. 1846), *Das Gewohnheitsrecht*. Erlangen, 1828-1837 (trad. *Il diritto consuetudinario*)
- Savigny (m. 1861), *System des heutigen römischen Rechts*. 1. Berlin, 1840 (trad. *Sistema di diritto romano attuale*)
- Otto von Gierke (m. 1921), *Deutsches Privatrecht*, I. Leipzig, 1895 (trad. *Diritto privato tedesco*)
- Francesco Calasso (m. 1965), *Storia e sistema delle fonti del diritto comune*. Milano, 1938
- Paolo Grossi (m. 2022), *Un diritto senza Stato...* (Quaderni fiorentini, 1996)
- Mario Caravale, *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*. Torino, 2013.

[Conte, 2009; Id., 2008 \(moodle\)](#)

La consuetudine nel Medioevo

Quae sit longa consuetudo

L'idea dialettica dei rapporti *consuetudo* vs. *lex* se ne porta dietro altre:

- *populus* vs. *Imperium*
- *diritto popolare* vs. *diritto romano* → es. diritti comunali (XII sec.)
- *diritto germanico* vs. *diritto romano* (tesi Gierke)
- *diritto consuetudinario* vs. *diritto romano* (tesi moderne)

A distanza di anni da queste elaborazioni noi possiamo tuttavia riavvicinarci al tema con occhi nuovi. Verifichiamo se questa lettura *dialettica* e *consuetudinaria* del Medioevo giuridico regga ancora la prova delle fonti.

[Conte, 2009; Id., 2008 \(moodle\)](#)

La consuetudine nel Medioevo

Consuetudini come autonomie popolari? Il Barbarossa e le consuetudini comunali.

Ambitious of restoring the splendour of the purple, Frederic the First invaded the republics of Lombardy with the arts of a statesman, the valour of a soldier, and the cruelty of a tyrant. **The recent discovery of the Pandects had renewed a science most favourable to despotism; and his venal advocates proclaimed the emperor the absolute master of the lives and properties of his subjects.** His royal prerogatives, in a less odious sense, were acknowledged in the diet of Roncaglia, and the revenue of Italy was fixed at thirty thousand pounds of silver, which were multiplied to an indefinite demand by the rapine of the fiscal officers. (E. Gibbon, *Decline and Fall of the Roman Empire*, vol. 5, first published in 1788. London – New York: 1910; repr. 1962, 200).

[Conte, 2009; Id., 2008 \(moodle\)](#)

La consuetudine nel Medioevo

Consuetudini come autonomie popolari? Il Barbarossa e le consuetudini comunali.

Pax Constantiae, cap. I, a. 1183 (eds. Falconi e Peveri, 1984)

*Nos Romanorum Imperator Fridericus et filius noster Henricus Romanorum rex concedimus vobis civitatibus, locis et personis societatis **regalia et consuetudines nostras*** tam in civitate quam extra civitatem...extra vero omnes consuetudines sine contradictione exerceatis quas ab antiquo exercuistis vel exercetis: scilicet in fodro et nemoribus et pascuis et pontibus, aquis et molendinis, sicut ab antiquo habere consuevistis vel habetis, in exercitu, in munitionibus civitatum, in iurisdictione tam in criminalibus causis quam in pecuniariis, intus et extra, et in ceteris que ad commoditatem spectant civitatum.*

cfr. l'apparato di Baldo degli Ubaldi alla pace di Costanza: [cap. 1, gl. sicut ab antiquo](#)

populi, per doctores. immo si pertinet ad bonum regimen, per ea
quæ sequuntur. standum est antiquitati.

b Confuetudines antiquæ
secundæ.

a *Sicut ab antiquo.* ¶ Ar. quod antiquæ consuetudines^b sunt ser-
uandæ. vnde dicit lex: ne quid contra longam consuetudinem
fiat, ad sollicitudinem suam reuocabit præses provincie. *Cod. quæ
sit long. consue. l. j. simile habes. Cod. de offic. ree. prouin. l. nullum. & Cod. de
serui. & aqua. l. si manifestè. & ff. de offic. procon. l. si in aliquam.* ¶ Et no.
hic expressum quod in^c piscuis, pontibus, aquis, & molendinis,
ac etiam in ipsis commoditatibus aquarum standum est anti-
quitati. Verbum enim habuistis^d & habetis, signat retro subsi-
stentiam iure consuetudinario: & quia illud erat amissum per
rebellionem, hic recuperatur per gratiam & reconciliationem.
*Cod. de sen. pas. l. si. sicut si postliminio^e ciuitas reuerfa esset. ff. de in-
iust. test. l. si quis filio. §. si. Et scias quod in^f præscribenda consuetu-
dine non est necesse allegare titulum: vt no. in cap. j. de rescri. lib. vj.
in nouel. & facit ad consuetudinem obseruandam. Cod. de agri. &
cen. l. domini prædiorum.* ¶ Item no. quod interdum fit aquæ^g distri-
butio arbitrio boni viri. ff. de va. & extraordi. cog. l. de usu. & not. in
Spec. de cau. pos. ubi vide. Imperator vult hic quod aqua perpetua,
& cursus eius & commoditas perpetuò non tollatur, nec alte-
retur. facit *C. de aquædu. l. si diligenter. lib. xj.* & loquitur tam de aqua
publica, quàm de aqua quæ seruit commoditatibus priuatorum:
& vt hic in verbo, personæ. & est expressum. *C. de aquædu. l. i. vsus
aqua. lib. xj. & extra de offi. delega. cum olim.*

e Ciuitas post-
liminio redi-
re quæadmo-
dum dicatur.
f Consuetudo
sine titulo
præscribi po-
test.
g Aquæ distri-
butio facièda
arbitrio boni
viri.

h Munire ci-
uitates quas
liberè.

b *Munitiõibus ciuitatũ.* licet^h enim Lombardis ciuitatem mu-
niri: aut hic. *de in. & de. l. ciuitas. l. ad. l. ciuitas. l. ad. l. ciuitas. l. ad.*

La consuetudine nel Medioevo

Consuetudini come autonomie popolari?

Già Puchta notava che la parola *consuetudo* ha, nelle fonti, almeno due significati: norma generale (*gewohnheitsrecht*) e prassi privata (*herkommen*). Forzando un po', possiamo distinguere anche noi tra consuetudine come norma oggettiva (*law*) e consuetudine come norma o diritto soggettivo (*right*).

La parola *consuetudo* può indicare una posizione giuridica individuale tutelabile in giudizio (i.e. stabilizzata).

La consuetudine nel Medioevo

Consuetudini come autonomie popolari?



Il *Dente cariato* di Roma Termini ospita diversi locali che il Comune di Roma (proprietario e locatore) ha concesso in locazione a privati esercenti (conduttori). Questi ultimi corrispondono regolarmente al Comune una certa somma di denaro (canone). Il Comune, per parte sua, ha però smarrito i contratti e con essi titolo e indicazione di scadenze, importi pattuiti etc...Questa circostanza potrebbe creare grande *incertezza del diritto*.

La consuetudine nel Medioevo

Consuetudine vs. diritto romano. Il *Liber Paradisus* (Bologna, 1257)

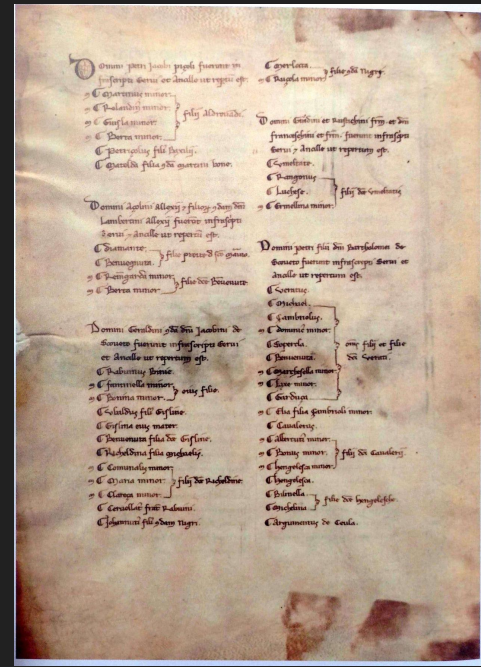
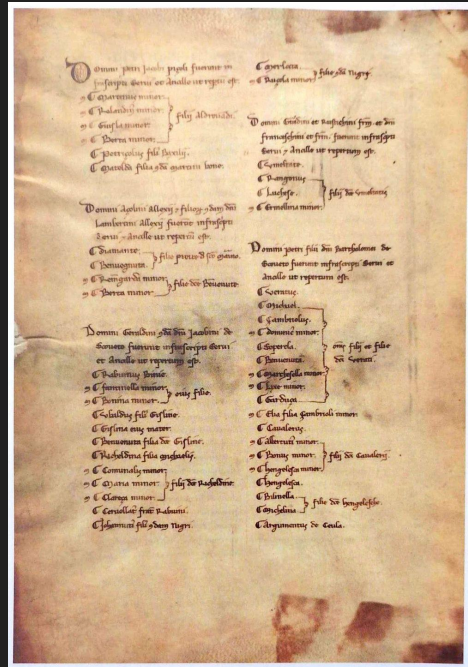
Liber Paradisus (ed. Antonelli, 2007)

*Cuius rei consideratione nobilis civitas Bononie que semper pro libertate pugnavit, **preteritorum memorans et futura providens** in honorem nostri redemptoris domini Iesu Christi nummario pretio redemit omnes quos in civitate Bononie ac episcopatu reperit servili conditione adstrictos et liberos esse decrevit inquisitione habita diligenti, statuens ne quis adstrictus aliqua servitute in civitate vel episcopatu Bononie deinceps audeat commorari, ne massa tam naturalis libertatis quam redempta pretio, ulterius corrumpi possit fermento aliquo servitutis, cum modicum fermento aliquo servitutis, cum modicum fermentum totam massam corrumpat et consortium unius mali bonos plurimos dehonestet.*

Considerando questa situazione, la nobile città di Bologna, che ha sempre combattuto per la libertà, **ricordando il passato e provvedendo per il futuro**, in onore del nostro redentore, il Signore Gesù Cristo, riscattò con denaro tutti coloro che trovò nella città e nella diocesi di Bologna vincolati a condizione servile, e, compiuta un'attenta indagine, decretò che fossero liberi; stabilendo inoltre che nessuno, legato da alcuna forma di servitù, osi d'ora in poi risiedere nella città o nella diocesi di Bologna, affinché una realtà (*massa*) così grande, sia della libertà naturale sia di quella riscattata a prezzo, non possa essere ulteriormente corrotta da alcun germe di servitù, poiché una piccola quantità di fermento corrompe tutta la massa e la compagnia di un solo malvagio disonora moltissimi buoni.

La consuetudine nel Medioevo

Consuetudine vs. diritto romano. Il *Liber Paradisus* (Bologna, 1257)



Liber Paradisus, cc. 1v e 23r
(Comune di Bologna)

La consuetudine nel Medioevo

Consuetudine vs. diritto romano. Il *Liber Paradisus* (Bologna, 1257)

- Gli statuti bolognesi ante-1257 attestano di una un'antica 'consuetudine' secondo la quale si può diventare servi, ascritti cioè alla terra di un *dominus*, per prescrizione trentennale. Questo, anche senza una manifestazione di volontà.
- La stessa insofferenza si ritrova tra i giuristi, per esempio due glossatori di inizio Duecento come Ugolino e Azzone.

E' interessante osservare che:

- La *consuetudo* bolognese ripropone in realtà una regola presente in una legge del 668 del re longobardo Grimoaldo, *Si servus aut ancilla per 30 annos...* (cfr. anche Liut. 77).
- I glossatori bolognesi sembrano molto ostili alla regola e per combatterla utilizzano il diritto romano.

La consuetudine nel Medioevo

Consuetudine vs. diritto romano. Il *Liber Paradisus* (Bologna, 1257)

Un commento del glossatore Azzone (m. 1225 c.), ed. Conte, 1996.

Set mihi contra uidetur hoc falsum propter generalem rationem positam in e. Cum scimus (C. 11.48.22.1), ubi dicitur quod non ex uno solo capite set ex pluribus capitibus liberi homines ad deteriolem conditionem sunt trahendi, <45.> et idcirco est necesse quod precedat promissio in scriptis uel sine scriptis quod perpetuo iure coloni se esse in fundo promittant et postea per xxx. annos in fundo permaneant.

Ma a me sembra invece che ciò [statuto bolognese] sia falso, a motivo della regola generale posta in *Cum scimus* (C. 11.48.22.1), dove si dice che non per un solo titolo, ma per più titoli, gli uomini liberi possono essere condotti a una condizione deteriore; e perciò è necessario che <a ciò> preceda una promessa, scritta o non scritta, con la quale <questi> si impegnino a essere coloni del fondo a titolo perpetuo, e poi che rimangano nel fondo per trent'anni.

La consuetudine nel Medioevo

Diritto romano, consuetudine e cambiamento (osservazioni conclusive)

- Nella letteratura giuridica medievale il termine *consuetudo* ha almeno due significati: norma e diritto 'soggettivo'. Da questo punto di vista, il termine rinvia a un uso tutelabile in giudizio.
- La *consuetudo* non si oppone al diritto romano come espressione dell'autonomia popolare contro le pretese dispotiche dell'Imperatore.
- Il diritto romano, sempre più centrale nell'esperienza giuridica dei secoli XII-XIII, si pone come risorsa a disposizione di società che cercano il cambiamento (e nuove *auctoritates* per realizzarlo).